

1501143-57.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501143-57.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501143-57.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN MONTEIRO ROSA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de IVAN MONTEIRO ROSA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal afirmando que em 02 de outubro de 2021, por volta de 17h40min, no prédio do Cadastro Único da Prefeitura Municipal, situado na rua João Mutinelli, nº 545, Centro, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, subtraiu para si, mediante escalada no prédio e rompimento do telhado, 1,3 kg de fios de cobre, avaliados em R\$ 259,00, pertencentes ao Município de Porto Ferreira. Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "o denunciado se dirigiu ao local dos fatos, onde funciona o Departamento de Cadastro Único da Prefeitura e, aproveitando-se da momentânea falta de vigilância, escalou o prédio, alcançando o telhado. Em seguida, ingressou na laje do imóvel mediante o rompimento das telhas e subtraiu 1,3 kg de fios de cobre. Todavia, guardas municipais foram acionados para verificar o motivo pelo qual o alarme do prédio havia disparado, no que flagraram o denunciado no telhado do imóvel. Ao notar a presença dos agentes públicos, o denunciado empreendeu fuga, mas foi detido, sendo o fato comunicado à Polícia Civil para averiguação. Formalmente interrogado pelo Delegado de Polícia em 04 de abril de 2022, o denunciado se recordou dos fatos e confessou a prática do furto, afirmando que iria vender os fios para comprar drogas (fl. 59)." A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação

de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do STF. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse". Nesse sentido é válida a lição do Desembargador Francisco Loureiro sobre a cessação da clandestinidade:

A posse é clandestina (clam) quando se adquire via processo de ocultamento em relação àquele contra quem é praticado o apossamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit., p. 23). É um defeito relativo: oculta-se da pessoa que tem interesse em retomar a posse, embora possa ser ela pública para os demais. Na violência, retira-se o poder de reação do possuidor, que conhece a agressão à sua posse. Na clandestinidade, o possuidor não percebe a violação de seu direito, e por isso não pode reagir. Questão relevante é saber se para cessar a clandestinidade deve o esbulhado ter ciência inequívoca de que a coisa acha-se nas mãos do possuidor injusto ou, em vez disso, basta que o novo possuidor não mais oculte sua conduta. O melhor entendimento é que não há necessidade de que a vítima tenha efetivo conhecimento do esbulho, mas que o esbulhador torne possível à vítima conhecê-lo (Pinto, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo, RT, 1987, p. 107-8). Torna-se pública a posse quando nasce para a vítima a possibilidade de conhecer o esbulho. Loureiro, Francisco Eduardo. Código civil comentado. 8ª ed., Barueri, Manole, 2014, p. 1070.

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais do que suficientes para atestar a consumação.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, pelo laudo pericial dos objetos de fls. 33/34, pelo laudo pericial do local fls. 37/3, pelo laudo técnico de avaliação

de fls. 42 e, sobretudo, pela prova oral colhida.
A autoria também é certa.

A representante da suposta vítima, Rosemar de Lourdes Mourão, na fase policial disse que "trabalha no Departamento de Cadastro Único da Prefeitura Municipal, onde realizam entrevistas diversas com a população, para concessão de benefícios como Bolsa Família; que, na data dos fatos, um sábado, estava em sua residência quando foi acionada pela Guarda Municipal, tendo em vista que o alarme de seu local de trabalho havia disparado; que, lá chegando constatou que os guardas já tinham prendido um indivíduo o qual tinha furtado fios do alarme, da câmera, da energia elétrica e do telefone; que, entrou no local onde fez uma breve vistoria, não constatando nenhum dano, somente o telhado foi danificado e os fios cortados; que, em seguida compareceram nesta Delegacia para registro dos fatos; que, a declarante afirma que não conhece o indivíduo que foi detido, de nome Ivan Monteiro Rosa, sendo pessoa estranha a seu relacionamento; que, não sabe dizer o prejuízo suportado pela Prefeitura quanto ao conserto dos danos provocados." Em juízo manteve sua versão. Disse que foram necessários reparos no imóvel.

A testemunha de acusação, o guarda municipal Tiago Daniel Caramori, na fase pré processual disse que "na data dos fatos efetuava patrulhamento de rotina com o GCM Ferreira, quando foram acionados pela base da Guarda (Cecom), haja vista que o alarme do prédio público onde funciona o Cadastro Unico da Prefeitura Municipal estava disparado; que, de imediato deslocaram-se ao local indicado, onde a princípio não constataram nenhum arrombamento, todavia instantes depois viram um indivíduo andando pelo telhado que ao perceber a guarnição policial, tentou se evadir pulando o muro dos fundos do local, o qual dá acesso a Papelaria Ideal, todavia conseguiram proceder a abordagem antes deste conseguir se evadir, sendo identificado como Ivan Monteiro Rosa, indivíduo este já conhecido nos meios policiais, pela prática de crimes contra o patrimônio nesta cidade; que, Ivan estava todo sujo e confessou naquele momento que havia arrombado o telhado o prédio em questão, acessado a laje de onde subtraía fios de cobre da parte elétrica, telefone e do próprio alarme; que, o depoente conseguiu subir no telhado de cerca de 3 metros de altura onde constatou que várias telhas haviam sido retiradas e que havia um saco plástico contendo em seu interior vários fios de cobre; que, o depoente percebeu que os fios estavam cortados e tentou achar o instrumento que Ivan teria utilizado para cortar os mesmos, porém não o encontrou, sendo que provavelmente dispensou quando da ação policial; que, Ivan conseguiu em pouco tempo, retirar cerca de um quilo e meio de fios do local, danificando a parte elétrica e de telefone e alarme do prédio; que, em seguida apresentaram Ivan nesta Delegacia onde foi elaborado boletim de ocorrência; que, não sabe precisar o prejuízo suportado pela Prefeitura diante da ação criminosa; que, esclarece ainda que tão logo chegaram no local dos fatos, ainda estava claro, por volta das 17:30hs." Em juízo manteve sua versão. Ivan foi abordado porque estava com a vestes sujas, o que levantou suspeitas. Os fios estavam no telhado da casa vizinha. Telhado tinha uns 3m de altura. O agente destelhou o imóvel para subtrair. Como ele cortou o fio do alarme a central de monitoramento foi acionada.

A testemunha de acusação, o guarda municipal Wilson Rogério Ferreira, na fase pré processual disse que "na data dos fatos efetuava patrulhamento de rotina com o GCM Caramuri, quando foram acionados pela base da Guarda (Cecom), haja vista que o alarme do prédio público onde funciona o Cadastro Unico da Prefeitura Municipal estava disparado; que, de imediato deslocaram-se ao local indicado, onde a princípio não constataram nenhum arrombamento, todavia instantes depois viram um indivíduo andando pelo telhado que ao perceber a guarnição policial, tentou se evadir pulando o muro dos fundos do local, o qual dá acesso a Papelaria Ideal, todavia conseguiram proceder a abordagem antes deste conseguir se evadir, sendo identificado como Ivan Monteiro Rosa, indivíduo este já conhecido nos meios policiais, pela prática de crimes contra o patrimônio nesta cidade; que, Ivan estava todo sujo e confessou naquele momento que havia arrombado o telhado o prédio em questão, acessado a laje de onde subtraía fios de cobre da parte elétrica, telefone e do próprio alarme; que, o GCM Caramuri conseguiu acessar o telhado onde

constatou que várias telhas haviam sido retiradas e que havia um saco plástico contendo em seu interior vários fios de cobre; que, o GCM Caramuri não conseguiu achar o instrumento que Ivan teria utilizado para cortar os fios, provavelmente dispensou o mesmo quando da ação policial; que, Ivan conseguiu em pouco tempo, retirar cerca de um quilo e meio de fios do local, danificando a parte elétrica e de telefone e alarme do prédio; que, em seguida apresentaram Ivan nesta Delegacia onde foi elaborado boletim de ocorrência; que, não sabe precisar o prejuízo suportado pela Prefeitura diante da ação criminosa; que, esclarece ainda que tão logo chegaram no local dos fatos, ainda estava claro, por volta das 17:30hs." Em juízo manteve sua versão. Avistaram Ivan pulando o muro do fundo.

A testemunha de defesa, JOSÉ VICENTE PAULO BRUNO, em juízo, disse que conhece Ivan e hoje ele trabalha em uma oficina mecânica. Antes ele usava drogas, hoje está firme em parar. Hoje arrumou uma companheira.

IVAN MONTEIRO ROSA, em declarações perante a autoridade policial, disse que "realmente praticou o furto em questão, sendo que subiu no telhado do prédio e retirou fios de cobre na intenção de vender para poder comprar drogas, uma vez que é dependente químico de crack e álcool há muitos anos, e no dia "teve uma recaída" e usou muito álcool e crack; que está arrependido do que ocorreu, sendo que atualmente parou de usar drogas e está trabalhando e frequentando uma igreja; que, no dia dos fatos foi detido por guardas municipais mas não se recorda o nome deles." Em juízo se disse inocente; está sendo falsamente acusado porque usava drogas. Tanto que quando foi abordado não tinha nada com ele. Não estava no imóvel no vizinho, estava na calçada, na rua. Estava vindo da casa de sua tia. Não tem participação nenhuma no caso. Não confessou na delegacia.

A materialidade do delito ficou inconteste.

A defesa alegou que o agente não foi preso em flagrante e que o delito é insignificante. Com a devida vênia, a liberação do agente pela autoridade policial não foi correta, eis que o somente a destruição da telha certamente exigiria de mão de obra mais que os 10% do salário mínimo, valor apontado pelo STJ como referência para a incidência da causa de atipicidade material.

O réu negou a autoria e disse que estava somente passando pelo local. A versão não parece crível, vez que os agentes públicos avistaram Ivan com as vestes sujas e saindo do imóvel (08°30' e 12°12') logo quando lá estiveram minutos após o acionamento do sistema de segurança. Estava no imóvel vizinho, em um sábado, próximo aos objetos subtraídos (cuja posse já havia sido invertida).

Não conseguiu explicar por qual razão estaria ali, se conhecia os donos do imóvel etc.

E não se nota qualquer animosidade dos agentes públicos, aparentemente desinteressados na causa, para incriminar falsamente o réu. Nada foi apontado.

A defesa atacou tão somente o depoimento na fase policial, o qual sequer será considerado na análise do feito.

Qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal): para sua caracterização é necessário que a violência seja praticada contra o obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando os vestígios tiverem desaparecido.

Embora alguns afirmem não incidir a qualificadora quando o objeto integra a própria coisa (p. ex., porta do carro furtado) sob o argumento de que o dano não ampliou a perda patrimonial da vítima. Essa perspectiva tem um vício de origem que cobra um preço caro na frente. As qualificadoras do furto não aumentam a reprovabilidade da conduta por conta do aumento do prejuízo da vítima, tanto que nenhuma aduz expressamente sobre o valor do bem. O objetivo delas é reprimir com maior rigor aquele que atenta de modo mais incisivo contra o bem jurídico, disposto a vencer as cautelas opostas pelos cidadãos de bem. Esse equívoco gera, ao final, uma contradição absolutamente inexplicável, de se punir na figura simples o "ladroão" de veículos e na forma qualificada aquele que quebra o vidro do carro para roubar os

pertences ali deixados.

No caso em exame, houve fratura de algumas telhas conforme laudo de fls. 37/38.

Qualificadora da escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal): considera-se escalada a entrada por via anormal, que exige um esforço fora do comum do agente para que se concretize a ação delitiva. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, ela ficou comprovada pelo laudo de fls. 37/39.

A existência de sistema de segurança e de vigilância eletrônica não torna o crime impossível, conforme entendimento do STJ:

Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

REsp 1385621/MG, Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015. Tema 924 dos Recursos Repetitivos.

Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos – diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da

pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que na certidão de antecedentes de fls. 66/69, há diversas condenações; a dos autos 0004380-57.2013.8.26.0472 configura mau antecedente (não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos - Tema 150 da Repercussão Geral do STF - HC 593.818/SC); as demais, por furto, são aptas a caracterizar reincidência específica. São elas aquelas referentes aos autos 0004018-55.2013.26.0472; 0001582-89.2014.8.26.0472; 0002369-84.2015.8.26.0472; 0006579-18.2014.8.26.0472; 0000048-47.2013.8.26.0472 e 0004233-60.2015.8.26.0472. Valoro quatro nesta fase e mais duas na fase seguinte.

Como cada mau antecedente é capaz de gerar um incremento de um sexto, elevo a sanção para 7 anos de reclusão e 302 dias-multa.

Comprovada a circunstância do rompimento de obstáculo, pela qual a lei confere especial gravidade ao delito dobrando a sua faixa de pena, e bastando a

circunstância da escalada para qualificar o furto, aumento a pena em mais dois anos e 116 dias-multa.

Fixo a pena-base no máximo legal.

Segunda etapa.

Presente a agravante da multirreincidência, pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), a qual deixa de gerar novo aumento em razão dos limites legais.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

A reincidência específica e a negativa das circunstâncias judiciais exigem o regime fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR IVAN MONTEIRO ROSA à pena de reclusão, pelo prazo de oito anos, em regime inicial fechado, bem como a 360 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 07 de junho de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA